

1527085-47.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... por policiais militares, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1527085-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527085-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN VINICIUS RAMOS GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Kelvin Vinícius Ramos Gonçalves, qualificado nos autos na fl. 21, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 06/novembro/2021, por volta das 09h40, na Rua Jair Rosa Pinto, 1700, Jaraguá, nesta comarca, trazia consigo 8,9g de cocaína, na forma de 65 pedras de crack, 39,8g de cocaína, na forma de 85 pedras de crack, 20,9g de cocaína, acondicionada em 59 invólucros plásticos, 23,8g de cocaína, acondicionadas em 76 invólucros plásticos, 103,3g de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em 43 invólucros plásticos e 112 mililitros de tricloroetileno, popularmente conhecido como lança-perfume, acondicionado em 31 fracos de vidro, sendo que

referidas substâncias são causadoras de dependência física e psíquica e o indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia que, o réu estava na posse de elevada e variada quantidade de drogas, embaladas na forma unitária para pronta entrega a terceiros usuários, em local conhecido pela mercancia de entorpecentes e na companhia de coautor não identificado, quando, ao perceber a presença de policiais militares na região, empreendeu fuga, momento em que dispensou ao chão a sacola em que guardava os entorpecentes; ocorre que, aludidos policiais já haviam notado a presença do denunciado e do segundo indivíduo no local, bem como o comportamento suspeito deles, razão pela qual, assim que ambos correram na tentativa de escapar, foram ao encalço dos suspeitos, logrando capturar o ora acusado, bem como apreender a sacola por ele dispensada; o coautor não identificado fugiu; em busca pessoal, foi encontrado na posse do averiguado a quantia de R\$ 287,50 em notas miúdas; já na sacola, foram localizadas as drogas acima descritas.

A denúncia (fls. 69/70) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/63), sendo a peça acusatória recebida em 26/novembro/2021 (fls. 73/74). Após a necessária notificação/citação (fl. 98), o réu apresentou resposta à acusação (fl. 122). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o denunciado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas considerações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição por falta de provas; em pedido subsidiário, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.

O Laudo de Constatação Prévia encontra-se nas fls. 09/13; o de Exame Químico Toxicológico nas fls. 105/108 e o Auto de Exibição e Apreensão das substâncias entorpecentes está nas fls. 14/15.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial restaram comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada a favor da Justiça Pública. Interrogado em Juízo, o acusado Kelvin Vinicius Ramos Gonçalves, 18 anos, negou a acusação; foi buscar maconha, mas os meninos não estavam; parou na rodinha e aguardou para ser servido; uma viatura apareceu e todos saíram correndo; o depoente não era o traficante; o traficante era um tal de Gabriel (áudio sistema SAJ).

Vejam os a prova do contraditório.

O depoente Maycon Brito de Moraes, policial militar, relatou que, ao entrar na rua dos fatos se deparou com três indivíduos; eles tentaram fugir ao ver a viatura; um deles pulou um muro para dentro de um prédio, sendo detido nesse local; enquanto fugia ele se desfez de uma bolsa onde havia drogas (lança perfume, crack, cocaína e maconha, além de R\$ 287,50); na ocasião, Kelvin confessou o tráfico dizendo que era seu primeiro dia; o réu também dispensou dois celulares (áudio sistema SAJ).

A testemunha Gustavo Machado Jardim, policial militar, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, o momento em que o réu fugiu para dentro de um condomínio, se desfazendo de uma mochila; essa mochila foi encontrada; havia entorpecentes dentro (cocaína, crack, maconha); indagado, o réu confessou informalmente a mercância ilícita dizendo que aquele era seu primeiro dia; os dois celulares estavam dentro da mochila e o réu disse que não eram dele (áudio sistema SAJ).

Como se vê, a oitiva das testemunhas presenciais, somadas ao Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Prévia e Exame Químico Toxicológico, tudo aponta no sentido de que a versão apresentada pela acusação é a verdadeira, eis que encontra simetria com as demais provas dos autos.

Com sua conduta, o réu se enquadra em, pelo menos, dois verbos do tipo previsto no artigo 33 da lei especial: trazer consigo.

Destarte, verifica-se que a ação penal procede.

De fato, os depoimentos dos policiais foram claros, serenos e seguros, dando conta da apreensão em poder do acusado, de razoável quantidade de substância

entorpecente, o suficiente a denotar o intuito da traficância.

A materialidade está estampada no Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), no Auto de Constatação Prévia (fls. 09/13) e no Exame Químico Toxicológico (fls. 105/108).

Este último demonstra que as substâncias apreendidas realmente eram cocaína e maconha.

Em que pese à insurgência da Defesa, a traficância restou devidamente caracterizada e comprovada.

Como visto, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo são coerentes e harmônicos e traduzem a certeza de que o réu, efetivamente, trazia consigo, dentro de uma sacola, razoável quantidade de cocaína e maconha, quando foi flagrado pelos agentes.

Portanto, restou claro que os policiais prenderam o acusado em flagrante em plena conduta típica, apreendendo em seu poder toda a cocaína e maconha encontrada.

Bem sabemos, como já dito acima, que incide nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aquele que é detido com expressiva quantidade de substância tóxica.

No caso concreto, a droga estava sendo trazida, para entrega a consumo de terceiros, pelo acusado em pela via pública, instante em que foi abordado por policiais militares, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que razoável, não define, por si só, a condição de traficante. Mas no presente caso, verifica-se que o réu foi flagrado trazendo consigo toda a cocaína e maconha apreendida dentro de uma sacola.

É sabido que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, forçoso reconhecer-se à configuração do crime em tela.

Ademais, por importante, mister se faz atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida (103,3g de maconha, 44,7g de cocaína e 48,7g de crack), o local (dentro de uma sacola) e as condições em que se desenvolveu a atividade delituosa (o acusado, ao perceber a presença policial, correu na tentativa de escapar, dispensou a sacola ao solo, porém foi abordado e as drogas localizadas).

Outrossim, não há que desmerecer os depoimentos dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que, a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade dos policiais ouvidos como testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem eles qualquer razão escusa para pretenderem prejudicar o acusado.

Assim, seus depoimentos não de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Rejeitada - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas - Acusada surpreendida mantendo em depósito drogas para imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência - Validade - Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição - Pena base alterada, mas sem reflexo na pena final - Redutor negado, mercê da expressiva quantidade de drogas apreendidas - Regime mantido em razão da gravidade da conduta - Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501099-78.2020.8.26.0567; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

APELAÇÃO - Tráfico ilícito de drogas, dano qualificado e resistência em concurso material - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra dos Policiais Militares - Validade - Precedentes - Circunstâncias fáticas que demonstram o comércio ilícito de drogas realizado pelo réu - Laudos periciais corroborando a ocorrência dos delitos de resistência e dano qualificado - Incabível a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Pleito de reconhecimento do redutor - Atendimento - Impossibilidade - Circunstâncias do caso concreto que indicam que o acusado se dedicava a atividades criminosas, no caso, ao tráfico habitual de drogas - Penas de todos os delitos fixadas de maneira apropriada - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501890-92.2018.8.26.0510; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021).

Não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas. Como já dito, não há sequer sugestão de que tivessem eles o mínimo interesse em incriminar o acusado injustamente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denúncia caluniosa. O relato do acusado encontra-se isolado no contexto probatório com o qual, aliás, colide frontalmente. O réu não apresentou em juízo qualquer testemunha que pudesse confirmar sua narrativa.

Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

O réu realizou conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Cód. Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Prevê o artigo 42 da Lei nº. 11.343/06: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu, ao tempo dos fatos, era primário (fl. 115).

Sua culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, no caso, é de média intensidade.

Sua personalidade e conduta social não de ser tidos por média intensidade.

Atento, ainda, ao motivo do delito - qual seja, o ânimo de auferir lucro, já que se dispôs a trazer a droga no meio da rua - bem como, atento às circunstâncias e funestas consequências da infração, que degrada a pessoa e compromete o tecido social e, em especial, considerando a grande quantidade de substâncias entorpecentes que o acusado trazia consigo, com os malefícios de todos conhecidos, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, chegando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta

e três) dias multa.

A pena base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da enorme quantidade de drogas apreendidas, que certamente atingiriam um grande número de pessoas, com consequências devastadoras à sociedade, providência que encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Colaciono jurisprudência no sentido da possibilidade de exasperação da pena base em virtude da quantidade de drogas:

Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Recursos defensivos – Pedidos de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários, da defesa de ALLAN, de redução das penas e de diminuição ou isenção da pena pecuniária em razão da sua precária situação econômica – Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a ambos os acusados, no tocante aos dois delitos – Penas-base majoradas em face da grande quantidade de maconha apreendida (3.489,42g) – Dosimetria das penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que levada a efeito mediante boa ponderação dos critérios da lei em vigor – O valor estipulado a título de sanção pecuniária, correspondente ao mínimo previsto na lei em vigor, não comporta redução por falta de amparo legal – Prisão cautelar do apelante ODAIR que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.(TJSP; Apelação Criminal 1500849-35.2018.8.26.0302; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, efetuo a diminuição de 1/6 (um sexto) chegando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, atento a Súmula 231, do STJ, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Por ter se envolvido com outro processo de tráfico após ser solto por esse, o réu não tem direito à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes.

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento de pena.

DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVADEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar Kelvin Vinicius Ramos Gonçalves, qualificado nos autos na fl. 21, incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento – em regime semiaberto – da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos.

Devido ao montante imposto, o réu não preenche os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, não devendo sua pena privativa de liberdade ser convertida por restritiva de direitos.

O acusado não está detido por esse processo, podendo recorrer desta em liberdade.

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino, se for o caso, o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que assistido pela Defensoria Pública.

P . I . C .

São Paulo, 13 de julho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.